

Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC

FUNDAMENTO PARA PROFERIR FALLO ABSOLUTORIO - Ausencia de ilicitud sustancial.

Se absuelve al investigado toda vez que, al realizar un análisis jurídico de todas las pruebas aportadas en el plenario, aun así, existe una duda razonable e insuperable (*"indubio pro disciplinado"*).

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 4, 5 y 13

IN DUBIO PRO DISCIPLINADO / DEBIDO PROCESO – Presunción de inocencia

"...la investigación arrojó inquietudes e interrogantes que imposibilitan atribuir responsabilidad disciplinaria al encartado. La duda, que para el caso concreto es razonable e insuperable en este estadio procesal..."

... el principio de Indubio Pro Disciplinado, se cimenta como un pilar del debido proceso y de la presunción de inocencia. Este último, catalogado como un logro en la configuración de los procesos judiciales al interior de los estados sociales de derecho, según el cual, la persona se reputa inocente hasta que un fallo judicial ejecutoriado no demuestre lo contrario. Así pues, el operador disciplinario para poder sancionar, debe llegar a tal convencimiento a través de pruebas legalmente recaudadas, al punto que logre desvirtuar la presunción de inocencia con la cual inició el encartado la actuación judicial."

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 6 y 9 - Corte Constitucional Sentencia C-244-96 del 30 de mayo de 1996

Dependencia:	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias
Número de proceso:	1704-01-2012-56
Número y fecha del fallo:	17413-47, del 16 de diciembre de 2013
Asunto:	Fallo de Primera Instancia - Verbal
Criterio de Selección:	Fallo absolutorio

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Una vez evacuado el trámite correspondiente al procedimiento verbal dentro del proceso administrativo disciplinario número 1704-01-2013-018, el Subdirector de Investigaciones

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-56

Disciplinarias de la Agencia ITRC, procede a proferir fallo de primera instancia, conforme a las exigencias del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 y de acuerdo a lo que sigue.

CARGO FORMULADO

Cargo

"Se le endilga al servidor público (XXXX) barrios torres, el no haber dado impulso al trámite requerido para el recurso de reconsideración interpuesto el 11 de mayo de 2009 por el representante legal de la empresa Disnorton Ltda, de tal forma que la administración no se pronunció dentro del término de una año establecido en el artículo 732 del estatuto tributario, con lo que se configuró el silencio administrativo positivo en el expediente de devoluciones personas jurídicas numero di 2008 2009 02107, el cual fue declarado mediante resolución número 0526 del 21 de febrero de 2012."

"De acuerdo con los registros que conforman la base de datos o Devicom que maneja la dirección seccional de impuesto de Bogotá (folios 238 y siguientes) es posible establecer que el investigado (XXXX) barrios torres, tuvo a su cargo el análisis del expediente y que el último registro a su nombre tiene por fecha el 6 de julio de 2009" y el recurso así interpuesto, fue recibido por el grupo interno de trabado de devoluciones de personas jurídicas desde el 13 de mayo de 2009, siendo sometido a reparto interno por la funcionaria Doris Cabrales de Muñoz, quien lo asignó a (XXXX), tal y como quedó registrado en el documento cuya copia reposa a folio 191.

CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

7.1. DEL CASO OBJETO DE ANÁLISIS

Toda decisión jurídica debe fundamentarse en las pruebas legalmente decretadas y practicadas en el curso de un proceso. Por su parte, el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, establece que sólo se podrá proferir fallo sancionatorio cuando haya prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado.

A efectos de iniciar el juicio de razonabilidad y ponderación de la responsabilidad, es preciso señalar que la falta disciplinaria está integrada por tres elementos estructurales: Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.

La tipicidad se define como la abstracta descripción de un comportamiento que el legislador ha definido como censurable. En el caso sub examine, la conducta investigada es típica, teniendo en cuenta que el artículo 48 No. 35 define como falta disciplinaria gravísima el dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo.

La antijuridicidad, está entendida en el ámbito disciplinario como la afectación del deber funcional sin justificación alguna. En el caso concreto, se predica que, en efecto, hay afectación en tanto hubo una actuación contumaz y pasiva por parte de la administración en la resolución de un recurso de reconsideración que interpusiera en su momento la empresa (XXX). Empero y

en gracia de discusión, si se aplicara un concepto amplio de la antijuridicidad, es decir, la ponderación del daño concreto de la conducta, tal y como se predica del juicio de antijuridicidad material en el ámbito penal, se dirá que el silencio administrativo positivo fue inocuo en tanto no se concretó ningún tipo de daño o afectación en el recaudo tributario.

Finalmente, la culpabilidad es el reproche subjetivo de la autoría del agente. Esto es, el análisis y valoración del comportamiento desde el aspecto finalístico que determinó al autor de la infracción a su consumación. Desde tal perspectiva, para iniciar un reproche de culpabilidad, es preciso en primera instancia establecer si el ahora investigado es el autor de la infracción.

Como se ha dicho a lo largo del análisis probatorio, principalmente al recaudado en la fase de juicio disciplinario, existen varias dudas acerca de la atribución funcional del disciplinado respecto del expediente DI 2008 2009 2107. Así pues, el operador disciplinario no tiene convencimiento pleno de que tal asunto administrativo haya sido entregado al disciplinado para su análisis, resolución o en su defecto, remisión al organismo competente.

Desde tal perspectiva, y concordante con lo manifestado por la defensa, la investigación arrojó inquietudes e interrogantes que imposibilitan atribuir responsabilidad disciplinaria al encartado. La duda, que para el caso concreto es razonable e insuperable en este estadio procesal, se sustenta a guisa de síntesis en los siguientes ítems.

1. El GIT de Devoluciones de Personas Jurídicas para los años 2009 y 2010, tuvo algunos inconvenientes de tipo organizacional en razón de una reestructuración.
2. El aplicativo DEVYCOM, el cual es empleado, entre otras cosas, para efectuar el reparto de expedientes de devoluciones no es infalible. Varios declarantes reconocieron la posibilidad de error e inconsistencia del reporte con la realidad.
3. A pesar de existir para la época de los hechos actas de reparto de expedientes, una vez estas fueron verificadas, se logró establecer que al disciplinado no se le hizo entrega del proceso No. 2009 2107.
4. No existe rastro en el aplicativo DEVYCOM del lugar físico en el cual permaneció el expediente desde la presentación del recurso hasta el requerimiento que hiciera el mismo contribuyente para su resolución.
5. El expediente fue entregado al archivo físico el 29 de marzo de 2009. Según los testimonios, excepcionalmente se vuelve a retirar estos procesos del archivo y cada vez que retornan, debe hacerse la inclusión en el aplicativo DEVYCOM. En el caso concreto, el expediente al parecer no volvió a ingresar al archivo puesto que no existe anotación al respecto, circunstancia generadora de duda en lo que atañe al lugar de permanencia del proceso pluricitado.
6. El GIT de Devoluciones no tiene entre sus atribuciones funcionales el desatar los recursos de reconsideración que presenten los contribuyentes, puesto que dicha función recae en el área jurídica; razón por la cual, no es lógico o acertado que se hiciera un nuevo reparto al interior del GIT de Devoluciones, al Dr. XXXX para resolver un recurso.
7. Si el expediente de marras hubiese estado cargado al disciplinado, en el acta de entrega del puesto de trabajo de fecha 2 de febrero de 2011, quien recibió debió haber advertido la

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-56

novedad y recibir el puesto con la anotación respectiva; circunstancia no acaecida en el caso sub examine.

8. SE probó que después del trámite de certificación de cobranzas y en general toda actuación de devoluciones, debe haber actuaciones y gestiones que se adelantan en uno, dos o máximo tres días. En lo que respecta al último cargue del expediente al disciplinado en el aplicativo DEVYCOM, se aprecia un lapso de aproximadamente un mes desde la última anotación; circunstancia cuya causa no está probada pero genera dudas respecto de la veracidad de la entrega efectiva del proceso.

9. Si el funcionario fue calificado en el desempeño de sus funciones como sobresaliente, minimiza tal circunstancia la posibilidad de un actuar descuidado o negligente.

10. La Dra. SOLY VEGA, Jefe de la División de Recaudación de la Seccional de Impuestos de Bogotá, certificó todos los expedientes que tuvo a cargo el disciplinado durante su permanencia en el GIT de Devoluciones, sin que se aprecie en dicho listado el expediente DI 2008 2009 2107.

Como puede apreciarse, le asiste razón a la defensa en sus apreciaciones defensivas, en el entendido de que la responsabilidad disciplinaria de su prohijado no está demostrada, contrario sensu, persiste en la investigación elementos de duda razonable e insuperable.

Desde tal perspectiva, el operador disciplinario se encuentra frente a una serie de inquietudes que imposibilitan proferir fallo sancionatorio en contra del señor XXXX, toda vez que no existe certeza más allá de toda duda razonable respecto de la responsabilidad disciplinaria.

Sea la oportunidad para indicar, que el principio de *Indubio Pro Disciplinado*, se cimienta como un pilar del debido proceso y de la presunción de inocencia. Este último, catalogado como un logro en la configuración de los procesos judiciales al interior de los estados sociales de derecho, según el cual, la persona se reputa inocente hasta que un fallo judicial ejecutoriado no demuestre lo contrario. Así pues, el operador disciplinario para poder sancionar, debe llegar a tal convencimiento a través de pruebas legalmente recaudadas, al punto que logre desvirtuar la presunción de inocencia con la cual inició el encartado la actuación judicial.

Respecto del principio de presunción de inocencia, la Honorable corte Constitucional, en sentencia T-581 de 1992, manifestó:

" Con la consagración de la presunción de inocencia como derecho fundamental constitucional extensivo a toda disciplina sancionatoria, se busca vincular a las autoridades que, en ejercicio de sus funciones impongan sanciones de cualquier índole. De esta forma, se quiere evitar la presencia de actuaciones arbitrarias, en la cual el funcionario unilateralmente imponga la sanción y que la presunción de inocencia que establece la Constitución, sólo sea desvirtuada a través de un proceso en donde el sindicado tenga la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa de la debida forma".

De otra parte, la jurisprudencia Constitucional ha manifestado frente a los principios de *indubio pro disciplinado* y presunción de inocencia, lo siguiente:

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-56

"El derecho fundamental que tiene toda persona a que se presume su inocencia, mientras no haya sido declarada responsable, se encuentra consagrado en nuestro Ordenamiento constitucional en el artículo 29, en estos términos: "Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable", lo que significa que nadie puede ser culpado de un hecho hasta tanto su culpabilidad no haya sido plenamente demostrada.

Este principio tiene aplicación no sólo en el enjuiciamiento de conductas delictivas, sino también en todo el ordenamiento sancionador -disciplinario, administrativo, contravencional, etc.-, y debe ser respetado por todas las autoridades a quienes compete ejercitar la potestad punitiva de i Estado.

Ahora bien: el principio general de derecho denominado "in dubio pro reo" de amplia utilización en materia delictiva, y que se venía aplicando en el proceso disciplinario por analogía, llevó al legislador a consagrar en la disposición que hoy se acusa, el in dubio pro disciplinado, según el cual, toda duda que se presente en el adelantamiento de procesos de esta índole, debe resolverse en favor del disciplinado.

El "*in dubio pro disciplinado*", al igual que el "*in dubio pro reo*" emana de la presunción de inocencia, pues ésta implica un juicio en lo que atañe a las pruebas y la obligación de dar un tratamiento especial al procesado.

Como es de todos sabido, el juez al realizar la valoración de la prueba, lo que ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando la Administración decide ejercer su potestad sancionatoria tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría o participación en la conducta tipificada como infracción disciplinaria es imputable al procesado. Recuérdese que en materia disciplinaria, la carga probatoria corresponde a la Administración o a la Procuraduría General de la Nación, según el caso; dependiendo de quién adelante la investigación, y son ellas quienes deben reunir todas las pruebas que consideren pertinentes y conducentes para demostrar la responsabilidad del disciplinado.

Una vez es contrastada la realidad procesal con los antecedentes jurisprudenciales expuestos, de Perogrullo es concluir que en el sub lite, el operador finalizó el ejercicio probatorio con una maremágnum de inquietudes insuperables que imposibilitan desde cualquier perspectiva, atribuir responsabilidad disciplinaria al encartado. Valga decir, el Despacho no cuenta con certeza más allá de toda duda razonable para sustentar una decisión sancionatoria.

Desde tal perspectiva, el principio de presunción de inocencia no ha sido desvirtuado, por lo que la decisión jurídica será la absolución del señor (XXXX), al no encontrarlo responsable del ilícito disciplinario del que fue objeto de imputación mediante citación de audiencia.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-56

PRIMERO: ABSOLVER DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA al funcionario (XXXX), identificada con la cédula de ciudadanía XX.225.827; por la conducta que a cada una le fue endilgada en el Auto de Citación Audiencia No. 1011-6 del 1 de julio de 2011, proferido dentro del presente proceso verbal disciplinario, toda vez que la misma carece de tipicidad, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: NOTIFICAR EN ESTRADOS la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la Ley 734 de 2002, a los sujetos procesales.

TERCERO: ADVERTIR al sujeto procesal que contra la presente decisión procede el **RECURSO DE APELACIÓN**, el cual de considerarse debe ser interpuesto y sustentado en la presente audiencia de conformidad con el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011.

CUARTO: En firme la presente decisión, **COMUNICARLA** a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el artículo 174 del Código Disciplinario Único.

QUINTO: REMITIR Informe de servidor público a la DIAN, para que inicie las acciones disciplinarias a que haya lugar, con ocasión a la indebida comunicación de funciones que se hicieron al señor XXXX, en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés, de acuerdo a la parte motiva de esta proveído.

En consideración a lo ordenado el numeral tercero de la presente decisión, este despacho corre traslado del recurso de apelación a la Doctora MARTHA YANETH QUIROZ BURGOS, conforme lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011. En este estado de la diligencia debo manifestar al despacho que no se interpondrá recurso de apelación a la decisión notificada.

JORGE ADRIANO MORENO PONCE
Subdirector Investigaciones Disciplinarias -ITRC
Director del Proceso

Proyectó: Dr. Andrés Felipe Vásquez Umaña – Secretario Ad-Hoc

Aprobó: Dr. Jorge Adriano Moreno Ponce, disciplinado y Apoderado (a) del (os) investigado (s)